

Los pactos *ex intervallo*, se los llamaban pactos desnudos porque estaban desprovistos de toda acción y estaban protegidos por la *exceptio pacti conventi* porque se los consideraba como un acuerdo independiente. Se exigió la obligatoriedad del pacto *ex intervallo* en el contrato de compra venta porque aún no era exigible su cumplimiento o era ejecutable y las cláusulas podían modificarse.

En los contratos de derecho estricto, dada su rígida estructura, tanto el pacto agregado *in continenti* como el adicionado *ex intervallo* carecían de eficacia jurídica, porque en los *iudicia stricti iuris* las facultades de interpretación estaban restringidas y las partes debían atenerse a lo estrictamente estipulado una vez realizado no podía haber modificaciones.

Con el paso del tiempo se le otorgó al pacto celebrado *incontinenti* acción para exigir su cumplimiento y al *intervallo*, solo una excepción, llegando a admitir como exigible el pacto de intereses agregado *incontinenti* al contrato de mutuo que era de derecho estricto, cuando el préstamo no consistiera en sumas de dinero, o fuesen sumas de dinero provenientes del fisco, o de los banqueros por ejemplo.

Pactum Additionis in Diem

El pacto de adjudicación a término (*in diem addictio*) era aquel en que el vendedor se reservaba la facultad de rescindir el contrato para el caso de que en cierto plazo se presentara otro comprador ofreciendo mejores condiciones, tales como un precio más alto, un término más corto o mayores garantías. Este acuerdo podía jugar como condición suspensiva o resolutoria, según cual hubiere sido la intención de las partes, es decir, que tenía por finalidad suspender la existencia de la venta o provocar su rescisión. En caso de duda debía considerarse que tenía por efecto rescindir el contrato principal, porque su inserción en el mismo se hacía por lo general para que produjera tal consecuencia.

Habiendo recibido el vendedor las ofertas de otros compradores estaba obligado a hacerlas conocer al comprador originario a fin de

que manifestase si aceptaba o no confirmar el negocio en las mismas condiciones que los nuevos pretendientes. En caso afirmativo debía ser preferido, en tanto que si no aceptaba, el contrato quedaba rescindido. El derecho que el pacto acordaba al vendedor para desistir del contrato no podía ser invocado por el comprador salvo convención en contrario.

En caso de que la venta hubiera sido hecha efectiva por varios vendedores y ellos no se pusieran de acuerdo sobre la aceptación de la oferta que hiciera el nuevo comprador, el primitivo adquirente estaba facultado a conservar la cosa si la hubiere comprado por un precio único. Si la adquisición lo hubiera sido por precios separados y se tratara de cosas divisibles, era admitido que cada enajenante se valiera del pacto independientemente por la parte que fuera propietario, resultando así que el primer comprador quedaba con el dominio de la porción del vendedor que no hubiera hecho uso del derecho de rescisión.

Revocada la venta por el ejercicio del pacto los efectos se retrotraían al día de la adquisición (*revocatio ex tunc*) y en consecuencia el comprador debía devolver la cosa con sus acciones y acrecentamiento y hacer cesar los derechos que hubieren establecido a favor del tercero, en tanto que el vendedor quedaba obligado a la restitución del precio de venta con sus intereses y a reconocer los gastos necesarios que el adquirente hubiere realizado. Si el comprador se negare a cumplir las obligaciones que le incumbían, el vendedor podía perseguir su ejecución mediante la *actio venditi*, propia de la venta, o valerse de la *praescriptis verbis* de aplicación a los *pacta adiecta* porque en éstos, a semejanza de los contratos innominados, de las dos partes obligadas una de ellas había cumplido la prestación. Si vencido el término establecido por el pacto, el vendedor no hubiera usado el derecho de rescisión, la venta quedaba confirmada.

Pactum de retrovendendo

El pacto de retroventa permitía al vendedor reservarse la facultad de volver a comprar la cosa dentro de cierto plazo, por el mismo precio o por un precio diferente, ya determinado o a determinarse. Este pacto también podía ser otorgado a favor del comprador cuando éste se reservaba el derecho de exigir que el vendedor volviera a adquirir la cosa vendida dentro de cierto tiempo por un precio determinado o a determinarse, tomando entonces el nombre de *pactum de retroemendo*.

El pacto de retroventa obligaba al comprador a revender al enajenante la cosa comprada cuando éste así lo exigiera, derecho que estaba generalmente limitado a un término convenido y en caso de que no se lo hubiera fijado, podía ejercérselo en cualquier momento. El vendedor debía pagar el precio pactado y el comprador devolver la cosa con sus accesorios y la falta de restitución por parte de éste le obligaba al resarcimiento de los daños y perjuicios por aplicación de los principios generales. Hasta que el vendedor no hubiera ejercido el derecho de recomprar la cosa, era libre el comprador para gravarla y aún para transmitirla en propiedad, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños e intereses, no pudiendo el vendedor atacar dichos actos porque el pacto originaba sólo una acción personal. El enajenante contaba con las acciones *venditi* y *praescriptis verbis* para hacer efectivo el pacto de retroventa.

Pactum Commissorium

El pacto comisorio o *lex commissoria*, era aquel acuerdo de voluntades en virtud del cual las partes contratantes convenían de que si una de ellas no cumplía con las obligaciones que le incumbían, perdía los derechos que hubiera adquirido por la celebración del contrato principal. Esta convención que podía acompañar a cualquier contrato excepto el de prenda, se aplicaba generalmente a la compra venta y se concedía a favor del vendedor quien podía hacerlo jugar para la

rescisión del contrato, apartarse de sus cláusulas y exigir el cumplimiento de la convención, pero la elección de uno de dichos derechos le impedía ejercer el otro.

El pacto comisorio podía concebirse bajo las mismas formas que el pacto *addictionis in diem*, es decir, como condición suspensiva o como condición resolutoria, produciendo sus efectos rescisorios cuando el comprador no cumplía su obligación de pagar el precio convenido en el plazo determinado y, en caso de duda, debía presumirse que las partes lo habían agregado para que jugara como condición resolutoria. En este pacto el solo vencimiento del plazo hacía incurrir en mora al deudor sin necesidad de interpelación, pero si el acreedor llegaba a aceptar parte del precio no podía pretender la rescisión del contrato.

Los efectos del pacto comisorio hacían que el vendedor restituyera la parte del precio que hubiera recibido, no incluyéndose en la misma lo que se le hubiera dado en concepto de arras o por otro título. Por su parte el comprador quedaba obligado a devolver la cosa en el estado en que la hubiera recibido, es decir, con todos sus accesorios y frutos percibidos libre de toda carga o gravamen. En lo que respecta a las consecuencias que la rescisión acarrearba a los actos de disposición efectuados por el comprador en el supuesto de que hubiera transferido la cosa a un tercero, no hay uniformidad en la doctrina.

Al igual que los otros pactos, el pacto comisorio acordaba al vendedor la *actio venditi* y la *actio praescriptis verbis* para exigir el cumplimiento de las obligaciones del comprador.

Pactum Protimeseos

El pacto de preferencia acordaba al vendedor el derecho de ser preferido sobre toda otra persona para adquirir la cosa en iguales condiciones, en caso de que el comprador quisiera venderla, por sus efectos, era similar al de retroventa, diferenciándose del mismo porque el vendedor tenía solamente un derecho preferencial, supeditado

al hecho de que el comprador procediera a enajenar la cosa, pero no lo autorizaba a exigir la reventa del bien adquirido.

El derecho de preferencia que acordaba este pacto y que los comentaristas han llamado *ius protimeseos*, podía surgir no solamente por convenio de partes, sino también por disposición de la ley o por un acto de última voluntad. También el *pactum* podía aplicarse a otros contratos distintos del de venta como cuando se daba preferencia para el arriendo a los poseedores de fundos públicos, sean del fisco o de los municipios.

Pactum Displicentiae

La convención se celebraba en interés del comprador, que daba a las partes el derecho de desistir del contrato dejando las cosas en el mismo estado que si la venta no se hubiera efectuado, es el pacto que los comentaristas llaman *pactum displicentiae*. Era muy usual en las ventas a prueba en las que el vendedor sometía el negocio al agrado o conformidad del comprador y por ello la *actio praescripti vervis*, igualmente aplicable, producía los mismos efectos que la *actio redhibitoria*.

El *pactum displicentiae* tenía la característica de que la facultad acordada al comprador para desistir del contrato podía ser dada con o sin límite de tiempo, siempre que ello se conviniera expresamente. En caso de que los contratantes no hubieran establecido un plazo, la ley suplía el silencio de las partes consagrando el término de sesenta días útiles para que el comprador efectuara la opción.

Pactum Reservatae Hypothecae

El pacto de reserva de hipoteca era aquella convención que acordaba al vendedor el derecho de reservarse una hipoteca sobre la cosa vendida como garantía por el pago del precio o del saldo que pudiere quedar. Dicho pacto que generalmente se constituía para facilitar los negocios de venta a crédito, no modificaba la situación jurídica del

comprador desde que la cosa era adquirida por él, entrando bajo su dominio aunque gravada con un derecho real de hipoteca a favor del vendedor. De esta manera el pacto garantizaba al vendedor por su crédito acordándole una preferencia con respecto a otras hipotecas que pudieran otorgarse o que ya se hubieran establecido. Como una variante, el vendedor podía reservarse el dominio de la cosa que enajenaba hasta el pago del precio convenido (*pactum reservati dominii*) y en el caso el comprador sólo recibía una posesión meramente precaria hasta tanto cumpliera con su obligación.

Pactum de non Alienando

El pacto de no enajenar era el que tenía por objeto impedir al comprador la enajenación de la cosa adquirida a cualquier persona. Era un compromiso por parte del comprador de no vender la cosa adquirida, provocaba la nulidad de la venta cuando el comprador no hubiese cumplido, porque el vendedor solamente podía perseguir la indemnización por daños y perjuicios mediante la *actio venditi* o la *praescriptis verbis*.

Pacta Praetoria

Se llamaron así a las convenciones que fueron protegidas por acciones in *factum conceptae* por ejemplo las *pacta praetoria*, el *constitutum*, los *recepta*, el *iusiurandum* y el *pactum hypotheca*.

El Constitutum

El pacto de *constituto* o *pecunia constituta* era la promesa de pagar dentro de cierto plazo, una suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles que adeudaba el promitente (*constitutum debiti proprii*) o que era debida por un tercero (*constitutum debiti alieni*).

En un principio, el *constituto* había tenido aplicación cuando un deudor, al no poder cumplir su obligación en el vencimiento del plazo convenido, conseguía que el acreedor le otorgara uno nuevo bajo

la formal promesa de saldar su deuda a la llegada del mismo. Como tal compromiso creaba al deudor una responsabilidad mayor frente al acreedor por haberle permitido una dilación en la ejecución de su obligación, la falta de cumplimiento del pacto era jurídicamente considerada como una falta.

Si ocurría esto se le daba al acreedor una *in factum actio* de carácter penal, la *actio de pecunia constituta* para obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios causados por ese incumplimiento.

Con el paso del tiempo el *constitutum* quedaban comprendidas las prestaciones de cualquier clase que pudiesen generar obligaciones que se podían reclama civilmente.

El *pactum de constitutum* podía realizarse sin el empleo de formalidad alguna, quedaba perfeccionado con el *consensus* de las partes. Tenía que haber una deuda anterior de cualquier origen, el deudor debía tomar a su cargo una prestación equivalente a la deuda originaria.

Al igual que con el pacto de *constituto* no producía la novación de la deuda anterior que siempre subsistía, el acreedor, para demandar el cumplimiento de la obligación, podía elegir entre la acción emergente de la deuda originaria y la acción propia del *constituto*. Hecha la opción, el acreedor no podía ejercitar la otra vía que quedaba extinguida.

La acción derivada del pacto llamada *actio de pecunia constituta*, fue creada por el edicto del pretor para exigir el pago de sumas de dinero o de otras cosas fungibles, pero cuando el *constitutum* se hizo aplicable a prestaciones de cualquier naturaleza, sirvió para hacer exigible toda clase de prestación. El plazo de prescripción de la acción fue de un año, luego se extendió a treinta años.

Los *Recepta*

Dicha denominación comprendía: tres convenciones de distinta aplicación, el *receptum argentarii*, el *receptum nautarum*, *cauponum et stabularium* y el *receptum arbitrii*.

El *receptum argentarii* era el compromiso contraído por un banquero con su cliente de hacer efectiva la deuda que éste tuviera con un tercero, en un día determinado. El cliente podía exigir al banquero el cumplimiento de lo pactado por medio de la *actio recepticia*, de origen pretoriano y que en el derecho justiniano fue substituida por la *actio de pecunia constituta* cuando el *receptum* se refundió con el *constitutum debiti alieni*.

El *receptum nautarum, cauponum et stabularium*, fue la declaración por la cual el naviero, el posadero y el dueño de un establo comprometían su responsabilidad por la destrucción o pérdida que pudieran sufrir las cosas que sus clientes dejaran bajo su custodia o la de sus dependientes. Dicha responsabilidad se extendía a toda clase de culpa y llegó a existir, aún sin que mediara convención, por el solo hecho de que los efectos y equipajes hubieran sido introducidos en el barco, posada o establo (*praestare custodiam*). También la responsabilidad se hizo extensiva a los perjuicios que hubieran ocasionado otros viajeros a pesar de que éstos no tenían relación alguna de dependencia con los guardadores. El pretor creó una *in factum actio* a favor de los propietarios de los efectos dejados en navíos, posadas o establos para que pudiera exigir la restitución de las cosas en el estado en que se encontraban en el momento de ser dadas en guarda.

El *receptum arbitrii* era aquel pacto pretorio en cuya virtud una persona elegida como árbitro se comprometía a decidir una cuestión cualquiera, en otros términos, significaba la aceptación del cargo de *arbiter* en una controversia en que las partes interesadas estuvieran de acuerdo en dirimirla sin la intervención de la autoridad judicial. Este tipo de arbitraje presentaba la particularidad de que no daba a las partes una acción para que pudieran compeler al árbitro a cumplir su encargo y la única coerción posible estaba a cargo del pretor que podía imponerle multas o decretar embargos de sus bienes.

El *Iusiurandum Voluntarium*

El juramento voluntario fue una convención no formal por la cual una persona que tenía un conflicto con otra, para evitar los trámites de un proceso judicial, aceptaba someterse al juramento que su contrincante prestara respecto del asunto que había que dirimir o solucionar.

La parte invitada a prestar juramento era libre de negarse a darlo en cuyo caso a nada quedaba obligado, o bien a prestarlo y entonces ambas partes debían someterse a los términos en que el mismo hubiera sido efectuado. Este juramento podía llevarse a cabo ante el juez o extrajudicialmente, de que tenía lugar a instancia tanto del acreedor como por el deudor y de que podía referirse a la totalidad del asunto debatido o sólo a un hecho concreto en discusión. Se le otorgaba a las partes una *actio in factum*, la *actio iuris iurandi*, para hacer cumplir sus resultados y una *exceptio iuris iurandi*, para el caso de que el juramento no hubiera sido prestado.

Pacta Legítima

Son aquellos en los que su fuerza obligatoria estaba dada por constituciones imperiales y que su ejecución podía ser perseguida por una condición, la *condictio ex lege*, por ejemplo: el pacto de intereses, la promesa de dote, el pacto de compromiso y la donación.

En el período el imperio se permitió acordar intereses y después exigirlos cuando se tratara de pactos sobre préstamos de cosas que no fueran dinero. Con el aspo del tiempo tuvo carácter obligatorio el pacto en el que se acordaban intereses sobre sumas de dinero cuando eran realizados por el fisco o por los banqueros.

Eran una pacta legítima éstos acuerdos de intereses sobre esas sumas de dinero.

La promesa de dote efectuada por simple convención a partir de Teodosio II (428) se le otorgó al marido acción para exigir el cumplimiento de la misma. Se le dio a éste pacto el carácter de legítimo.

El pacto de compromiso

Por éste pacto varias personas se ponían de acuerdo en designar un árbitro para que resuelva una situación de conflicto y aceptar la sentencia que dictase.

Al principio no tuvo carácter obligatorio salvo que se hiciera bajo una *estipulatio* o cláusula penal.

En el derecho justiniano se volvió obligatorio el laudo arbitral, cuando las partes hubieran firmado el compromiso y no lo hubieran impugnado en el término de diez días, dándoles una *in factum actio* o una *condictio ex lege*.

No quedaban comprendidas las cuestiones de orden público, sobre el estado de las personas. El fallo era inapelable.

Elementos de los contratos

Se clasifican los elementos en esenciales, naturales y accidentales.

Esenciales

Sin ellos el contrato no puede tener existencia jurídica. La capacidad y el consentimiento de las partes, el objeto y la causa, de aquellos otros que sólo se exigen para determinados contratos, como serían las palabras sacramentales de la *sponsio* por ejemplo.

Capacidad: Se hace referencia aquí a la capacidad jurídica de las partes para llevar adelante los actos negociales.

Consentimiento: *Se refiere a que las partes expresen su consensus o acuerdo de realizar tal o cual contrato.*

Objeto: *Es lo que deben realizar las partes que acordaron contratar, el objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o susceptible de serlo.*

Causa: *La voluntad de las partes que da nacimiento al contrato va unida a un fin, el origentiene o persigue un interés.*

Naturales: son aquellos que, pueden ser excluidos por las partes por medio de una cláusula expresa.

Accidentales: son aquellos que dependen única y exclusivamente de la voluntad de las partes, son la condición, el plazo y el modo.

Clasificación

Contratos a título oneroso y a título gratuito

Es a título oneroso cuando se genera una contraprestación valorada desde el punto de vista económico entre las partes intervinientes, de manera recíproca.

Es a título gratuito cuando esa contraparte no existe, como en el depósito.

Contratos unilaterales y bilaterales

Según se den origen a las obligaciones para una sola parte, por ejemplo, el mutuo, o para ambas, por ejemplo, la compraventa.

Los contratos bilaterales o sinalagmáticos, se distinguen en: sinalagmáticos perfectos (nacen obligaciones recíprocas entre las partes, como en la compraventa y la locación) y sinalagmáticos imperfectos (nacen obligaciones para una de las partes, pero eventualmente puede nacer para la otra a posteriori; por ejemplo: el depósito, en el que las obligaciones son solo para el depositario, pero este puede obligar al depositante si pareciera alguna situación que así lo exigiera.

Contratos de ius civile y contratos de ius gentium

Los contratos de ius civile provienen del derecho positivo romano. Dan origen a acciones iuris stricti, la labor del juez se reduce a comprobar su existencia o inexistencia, condenando o absolviendo.

Los contratos de ius gentium nacieron de la de las vinculaciones entre los distintos pueblos, y fueron admitidos por el pretor peregrino, por ejemplo: la compraventa y la sociedad. Dan lugar a acciones bonae fidei.

Efectos y extinción de las obligaciones

I. Efectos de las obligaciones

Efecto de las obligaciones entre el deudor y el acreedor. Ejecución.

Cuando nace un vínculo crediticio entre un deudor y un acreedor se pretende que ambos cumplan con lo que se han comprometido al inicio. A veces se cumplen estas perspectivas y en otras ocasiones no.

El cumplimiento de la prestación por parte del deudor podía ser voluntario o se hacía de manera forzada.

Cuando las perspectivas de acreedor no se cumplen se debe ejecutar la deuda. En el sistema de las *Legis Actiones* había dos formas muy antiguas: la *manus iniectio* y la *pignoris capio*, la ley pre establecía en qué casos debían aplicarse para que prospere.

Quedaba fuera de la órbita de la ejecución las obligaciones naturales ya que no disponían de ninguna *actio* para demandar su cumplimiento.

Al principio se exigió del deudor que cumpliera entregando lo que se había comprometido pero con el aspo del tiempo se le dio otra la posibilidad de que entregue algo diferente para extinguir su vín-

culo con el acreedor, en la medida que éste último aceptara. Para el caso de su aceptación tramitaba como una *exceptio* siendo sus efectos de pleno derecho o ipso iure.

La prestación debía ser cumplida en su totalidad y nadie podía ser obligado a recibir pagos parciales si no era lo que se había acordado.

El efecto era el mismo si tanto el cumplimiento de la prestación era realizado personalmente por el deudor o por un mandatario o por un gestor de negocios; como quién recibía la prestación, si era el acreedor un mandatario suyo o un agregado por causa de pago.

Si la prestación consistía en dinero no había mayores dificultades al momento de cumplir, cuando era en especies, la pérdida de la cosa salvo que, fuera por caso fortuito o fuerza mayor, el deudor debía responder igual sobre todo en los casos de deuda de género.

Cuando se trataba de obligaciones de hacer o no hacer, el cumplimiento no podía hacerse en especie sin el consentimiento del acreedor.

Si el deudor era enjuiciado, su prestación cualquiera fuese se podía transformar en una suma de dinero determinado al momento de la *litis contestatio* si eran acciones de derecho estricto. Si eran acciones de buena fe se determinaba al momento de la sentencia.

Al momento de determinarse qué es lo que el deudor debe cumplir se tenía en cuenta el llamado *damnum emergens* o sea el perjuicio verdadero que tuvo el demandante, lo perdido patrimonialmente.

Con el paso del tiempo se tuvieron en cuenta otros perjuicios como la ganancia que se dejó de percibir denominada *lucrum cessans*.

Ejecución de las obligaciones

En los primeros tiempos para ejecutar las deudas de deudor insolvente, se recurrieron a distintos mecanismos jurídicos: al principio la ejecución en la persona del deudor insolvente a través de la *manus iniectio*, luego con la sanción de la *Lex Poetelia Papiria*, en el año 326 a. C. por ésta última se prohibía la ejecución del deudor sobre su per-

sona para realizarla sobre su patrimonio (ejecución por la *Bonorum Venditio* y otros procedimientos similares).

Cuando una persona contrae una obligación con otra en ambos se generara una expectativa, tanto del deudor de cancelar su deuda, como la del acreedor de que reciba la prestación dada.

Esa obligación contraída por el deudor tendrá efectos ya sea al cancelar la deuda como al no cancelar la misma.

En las obligaciones de derecho estricto con respecto el deudor, respondía con su cuerpo (*manus iniectio*) en caso de incumplimiento, en cambio, si la obligación era del derecho de gentes, respondía con su patrimonio; además, cuando la obligación era del derecho estricto el *iudex* tenía menos facultades que cuando la obligación era del derecho de gentes o de buena fe, ya que tratándose de la obligación del derecho de estricto el *iudex* debía aplicar el derecho ajustándose al caso sin tener en cuenta las circunstancias particulares (equidad).

Bonorum venditio

Una de las formas de ejecución de las obligaciones incumplidas fue la *Bonorum venditio*. Era un procedimiento creado por el pretor, y consistía en que cuando el deudor no cumplía con la prestación objeto de la obligación, el acreedor podía pedirle al magistrado una orden escrita que lo autorizaba a entrar al domicilio del deudor, esa orden escrita recibe el nombre de *missio in possessionem*. Contra el deudor que se opusiera a obedecer esa orden, o cuando un tercero impedía al acreedor el acceso al domicilio del deudor, se daba un interdicto, que se conocía como interdicto *quorum bonorum*, de carácter universal.

En el supuesto de que el deudor dejara entrar en su domicilio al acreedor, el acreedor iba acompañado de una persona llamada síndico, designado por el magistrado al pedir la *missio in possessionem*, encargado de realizar un inventario con los bienes del deudor, que comprendía los bienes corporales como y los bienes incorporeales derechos, pero se hacía también las nóminas de las deudas.

Era suficiente con que el acreedor se presente ante el magistrado y a partir de ese momento se publicaban afiches o proscripciones en lugares públicos con el fin de que se enteraran otros acreedores y la población en general. Se publicaban durante 30 días si el deudor estaba vivo y si ya había fallecido durante 15 días.

Luego se procedía a confeccionar los cuadernos donde figuran los créditos a favor del deudor y las deudas para indicar esta operación y se licitaba el patrimonio el efecto se le adjudicaba al acreedor, o cualquier que ofreciera a pagar el porcentaje más alto de los créditos contra el deudor, en igualdad de porcentajes al que ofreciera mejores garantías de pago, y así la persona que resultaba adjudicataria del patrimonio del deudor recibía el nombre de *Bonorum Emptor*.

La *bonorum venditio* es una sucesión a título universal entre vivos, que transfería los bienes del deudor; quedando éste desapoderado de los mismos y acarreándole la tacha de infamia. Ciertos deudores estaban dispensados de esta ejecución y en lugar de ésta se operaba *bonorum distractio*: eran los componentes de las clases senatoriales y los deudores de buena fe, que hacían cesión de sus y en tal caso se procedía a la venta de las cosas singulares hasta alcanzar un precio suficiente como para atender la justa existencia de los acreedores.

En la época de Justiniano la *bonorum venditio* ha desaparecido y ocupa su lugar la *bonorum distractio* para todos los casos.

Ahora veremos los casos en que el deudor obraba en forma maliciosa y el remedio jurídico que se buscó a través de la acción que se verá a continuación.

Acción Pauliana o revocatoria

Cuando el deudor no podía cumplir con la prestación debida, podía ser porque realmente no podía y en otras ocasiones el deudor ejercía un fraude en contra de su acreedor, este se entendía en el sentido de daño. Hay fraude del deudor cuando éste realiza actos de

enajenación (enajenar: pasar a otro el dominio de una cosa) en perjuicio de sus acreedores, desprendiéndose de su propio patrimonio.

El deudor puede disponer de sus bienes libremente sin que por ello los acreedores pudieran impedirlo. Esto podía llevar a que disminuyera su masa patrimonial y no cumpliera con la prestación de los acreedores. El patrimonio les servía a los acreedores para reclamar ante el incumplimiento, pero el deudor a sabiendas los despojaba de ésta posibilidad.

Los reclamos de los acreedores eran tenidos en cuenta a nivel judicial cuando el deudor se insolventaba fraudulentamente, con el fin de causarles perjuicios a estos en sus pretensiones como tales (acreedores).

En el supuesto de fraude del deudor hay que distinguir dos clases de actos de enajenación que el deudor puede realizar en perjuicio de sus acreedores, pueden ser a título gratuito o a título oneroso. A título gratuito era cuando el deudor hace la enajenación sin que el beneficiario de la misma, el tercero que intervenía otorgare alguna contraprestación, por ejemplo la donación es un acto de liberalidad, si el acto jurídico que causa el empobrecimiento del deudor era con este título (gratuito) podía ser revocado sin mayores inconvenientes incluso podía oponerse a terceros.

En cambio el acto a título oneroso cuando la enajenación que hace el deudor hay una contraprestación que debe realizar la otra parte, por ejemplo: compraventa, no era alcanzada por la acción Pauliana.

La consecuencia que traía el fraude era el empobrecimiento del propio deudor a través de uno o varios actos jurídicos; el perjuicio patrimonial al acreedor; el deudor tenía que tener conciencia del fraude o sea intención de causar daño.

Efectos accidentales del incumplimiento

Ahora pasamos a otro aspecto del tema que se está desarrollando que son los efectos accidentales, llamados así porque son circunstan-

cias que pueden darse o no y llevan al incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, se distinguen los siguientes casos:

Caso fortuito o fuerza mayor

Es todo evento ajeno a la voluntad del deudor producido por obra de la naturaleza o del hecho de un tercero del que el deudor no sea responsable.

Caso fortuito es un acontecimiento de la naturaleza que no puede preverse, en cambio fuerza mayor es el acontecimiento que siendo previsto no pudo ser evitado (inundación, terremoto, ruina, naufragio, etc).

Pero para que el deudor no responda por su incumplimiento (caso fortuito o fuerza mayor), es necesario que cuando tiene el lugar el caso fortuito o fuerza mayor, no estuviese en mora en el cumplimiento de la obligación.

Mora

Es el retardo o demora culpable en el cumplimiento de la prestación (mora del deudor) que no eran el resultado de la fuerza mayor, ni por culpa del acreedor, ni por error excusable.

También podía ser el retraso en recibirla (mora del acreedor).

Uno de los requisitos para que el reclamo prospere es la interpelación o acto formal por el cual el acreedor en forma judicial o extrajudicial, intima al deudor al cumplimiento de la prestación.

Mora del deudor

Para que la mora del deudor se volviera exigible el acreedor debía hacer la *interpellatio* de manera personal al deudor.

Si el deudor muere la deuda se transmite a los herederos.

Éste debe hacerse cargo de los riesgos generados por la cosa. Debe, además responder por los daños y perjuicios generados por su mora y por los intereses que generan su retraso.

Mora del acreedor

La mora del acreedor tiene lugar cuando el acreedor, de manera arbitraria, injustificada se niega a recibir la prestación que es objeto de la obligación, en el tiempo y lugar acordados.

Además del retraso objetivo, se requiere la intencionalidad dolosa o culposa del mismo ya que se niega a recibir la prestación.

Las consecuencias de dicho retraso son: Los riesgos por la pérdida o deterioro de la cosa, quedaban a su cargo además de indemnizar los daños y perjuicios causados por su retraso, como así también los gastos generados por el cuidado y conservación de la cosa. También interrumpía los intereses devengados. Pago por consignación:

Era cuando el deudor se veía obligado a depositar la cosa en un lugar público por ejemplo un templo, ello significaba que se liberaba definitivamente.

El dolo como causal de incumplimiento de las obligaciones

El dolo es una maniobra malintencionada que una de las partes utiliza para obtener una ventaja patrimonial en desmedro de la otra parte, por lo tanto quien actúa con dolo utiliza la actitud de inducir en error al contrario (engaño), además la ventaja patrimonial tiene que ser grave para quién se beneficia. No puede haber dolo de ambas partes porque ambos habrían violado la ley y no podrían invocar derecho alguno en la justicia a través de una *actio*. La *actio* por dolo prospera cuando hay buena fe de una de las partes.

La Culpa

Era otra causal de incumplimiento. Los romanos distinguieron la culpa grave de la culpa *levis*. La culpa grave se asimila al dolo, es toda conducta prudente o negligente que provoca un grave perjuicio patrimonial, es difícil saber si realmente se actuó con dolo o con negligencia en ciertos casos por las características del elemento subjetivo.

La diferencia entre el dolo y al culpa se mide por la gravedad o no del daño inferido.

La responsabilidad

La responsabilidad por incumplimiento en tiempos del procedimiento formulario, si el deudor incurría en dolo o culpa debía indemnizar al acreedor por daños y perjuicios; mientras en tiempos del procedimiento extraordinario el deudor era condenado a cumplir con la prestación pactada.

La condena se podía establecer, en base a un cálculo aproximado, según el valor de la cosa, o tener en cuenta lo que declaraba el actor bajo juramento.

Daños y perjuicios

Se llama daño a la lesión del interés o pretensiones jurídicas que tiene el acreedor con respecto a la cosa u objeto de la obligación.

Los daños pueden ser: emergente (lesión al interés del acreedor); o lucro cesante: es el beneficio que hubiera podido obtener el acreedor si el deudor hubiera cumplido con la prestación.

A su vez los daños pueden ser: directos: cuando es la consecuencia inmediata del incumplimiento de la obligación.

Los daños indirectos: Son aquellos en los que el incumplimiento de la obligación afecta a otros derechos, o intereses del acreedor.

II. Extinción de las obligaciones

En el período clásico las obligaciones quedaban extinguidas por las siguientes causales:

- Las obligaciones de origen delictivo quedaban extinguidas por la muerte del delincuente; y en las obligaciones llamadas *vindictam*, por la muerte de la víctima.
- El crédito del *adstipulator* y el de la mujer en restitución de dote, no pasaban a sus herederos.

-Las deudas de las cauciones *sponditores* y *fideipromissores*) terminaban por la muerte de éstos.

-Por padecer una *capitisdeminutio*, producía la extinción de créditos en ciertos casos y de otras deudas que las nacidas de un delito, por desaparición jurídica de su titular o por absorción del patrimonio, por parte de otro.

-Por haberse cumplido el plazo de prescripción y no se podía accionar en reclamo de la deuda. A veces era consecuencia de que el Pretor creaba acciones que solo podían ejercerse dentro del año como regla general pero excepcionalmente se establecían otros plazos: la querella *inofficiosi* tenía un plazo de cinco años; las obligaciones de los *sponditores* y *fideipromissores* se extinguían a los dos años de acuerdo a lo dispuesto por la *Lex Furia*.

Para que un deudor pueda extinguir su deuda con el acreedor existían formas diferentes:

Solutio per aes et libram

Las partes quedaban desobligadas por el ritual del cobre y la balanza. El mismo está admitido solamente en ciertos casos, como por ejemplo, si la deuda proviene de un acto *per aes et libram*. Se requiere la presencia de por lo menos cinco testigos y el *libripens*.

Aceptilatio

Era cuando las partes se comprometían a entregar el objeto a través de la *stipulatio*, se podía a través de un método contrario llamado *acceptilatio* que consistía en una pregunta y una respuesta y en este método no se exigía ninguna formalidad por ejemplo, ¿tienes por recibido el caballo?, a lo que la contraparte respondía: “si lo tengo”.

Categoría de extinción *ipso iure*

Encontramos varias formas. Recibe ésta denominación la obligación que se extingue mediante efecto del derecho objetivo, de modo que el deudor no necesita pedir al magistrado que le dé una excepción para repeler la acción del acreedor, basta con invocarlo y probarlo.

El pago

Es cumplir con la prestación adeudada.

Las personas que pueden efectuarlo y recibirlo

En principio el pago era hecho por el deudor; sin embargo podían hacerlo otros terceros: como el fiador por el *dominus negoti*, el deudor solidario o un tercero.

De ésta manera, podía pagar un tercero que recibió mandato del deudor, pagando extingue la obligación y tiene contra su mandante para que le reembolse lo pagado, la acción de mandato contraria. Puede pagar también un tercero que hace como gestor de negocios (*quasi* contrato parecido al mandato), pero en el que falta el consentimiento de las partes, en este caso se extingue también la obligación y el gestor puede pedir el reembolso por los gastos que le pudo haber causado el deudor. Y por último queda el caso en que el tercero pague contra su voluntad del deudor; en ese caso, en principio la obligación se extingue, pero el tercero no tiene derecho a reembolso contra el deudor, si no en la medida que el deudor se hubiera enriquecido con el pago.

En cuanto a las personas que pueden recibir el pago, sólo puede recibirlo el acreedor; si el deudor paga a quien no es acreedor no se libera ni extingue la deuda.

Formas de pago

La forma de pago depende de la naturaleza de la prestación, si se trata de un *dare*, o sea de transmitir la propiedad o constituir un derecho real sobre la cosa, se tienen que cumplir con las formalidades que se exigen para la constitución de esos derechos reales; si se trata de un *facere* o un *non-facere*, no hay forma alguna, ya que se trata de hechos u omisiones; si es un *prestare*, para constituir un derecho de crédito sobre la cosa la formalidad es propia de la *traditio*.

El lugar de pago

Es el lugar convenido por las partes para el cumplimiento de la prestación. Si no hay lugar convenido, depende de la naturaleza de la cosa, por ejemplo, si se trata de cosa inmueble, donde ésta se encuentra ubicada.

Si es una cosa mueble se entregará en el domicilio del deudor.

Si la obligación es consecuencia de un hecho ilícito, el lugar es donde se cometió el hecho o el lugar donde tiene el domicilio el deudor, a elección del acreedor.

Con respecto al lugar surge la *actio eo quod certo loco*. Esta acción es de origen pretoriano surgió a raíz de que podía ocurrir que por voluntad del deudor no pudiera en ningún momento, el acreedor exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación.

Para reclamar la prestación en un lugar que no correspondía, por esa razón el pretor dio la *actio eo quod certo loco*, le permite al acreedor en todos los casos demandar la prestación en un lugar distinto al establecido.

Tiempo de pago

El tiempo de pago si la obligación surge de un contrato, es el fijado por las partes, pero también puede derivar de la naturaleza del contrato.

Si no hay plazo fijado la obligación se hace exigible al primer requerimiento del acreedor.

En el derecho romano el plazo está siempre establecido a favor del deudor.

El plazo puede estar establecido:

1. A favor del deudor: el deudor puede pagarle al acreedor en cualquier momento.
2. A favor del acreedor: el acreedor puede exigir el pago en cualquier momento.
3. A favor del acreedor y del deudor: Ninguno puede pagar

sin el consentimiento de la otra parte, antes de vencido el plazo.

Si el deudor quiere pagar antes, el acreedor tiene la obligación de aceptar el pago, en cuyo caso el deudor tiene el derecho de descontar los intereses (si la obligación los devenga), descuento que recibe el nombre de *Inter usurium*.

El deudor debe pagar la cosa u objeto de la obligación no puede compeler al acreedor a recibir cosa diferente aunque sea de mayor valor ni tampoco puede liberarse haciendo pagos parciales.

Hay excepciones: la excepción de que el deudor pueda compeler al acreedor a recibir cosa distinta se llama *datio in solutum* (dación en pago).

La dación en pago tiene lugar cuando el deudor se libera cumpliendo con una prestación distinta a la que es objeto de la obligación.

Como excepción de pago existe el principio de que el deudor puede realizar el pago con beneficio de competencia; el deudor paga sólo hasta el límite que le permita alimentarse a él y su familia. (No todos tienen este beneficio, solo los socios entre sí por deudas provenientes de la sociedad).

El pago por consignación

Tiene lugar cuando el deudor le paga por depósito judicial y media una sentencia judicial que declara válido dicho depósito y hace las veces de pago.

Asimismo se produce cuando el deudor ofrece pagar al acreedor y este se niega a recibir el pago.

Efectos del pago

El pago libera al deudor y extingue las garantías, sean reales o personales, y obliga al acreedor a dar certeza de pago al deudor, restituyéndole los instrumentos que el deudor hubiese firmado.

La novación

Junto a la *litis contestatio* se la tiene como un modo de extinción pero en realidad en los dos casos no se extingue se transforman, en una nueva.

Es otro modo de extinguir obligaciones del derecho civil; opera ipso iure –de plenos derecho–.

La novación se define como la transferencia y traslación de una obligación en otra posterior.

Para que la novación exista se tiene que dar los siguientes requisitos:

1. Tiene que existir una obligación anterior.
2. En la nueva obligación se tiene que cambiar algo a excepción del objeto porque si se cambiaran este se extinguiría la obligación anterior y la nueva obligación que surge no tendría que ver con la extinguida ya que la naturaleza de la novación no es extinguir sino cambiar
3. Se puede cambiar la causa jurídica que dio origen a la primera obligación por ejemplo lo que se prometió por la *sponsio* ahora se promete por *stipulatio*.
4. También se puede cambiar la persona del deudor o del acreedor.

La novación se producía por la estipulación que aparecía en los contratos: la *nominatranscriptitia*. Si la obligación que se nova es nula, se anulaba la obligación; si estaba sometida a condición y ésta no se cumplía también quedaba sin efecto la nueva obligación, a no ser que las partes dispusieran lo contrario.

La compensación

No se trató de un modo directo de extinción de las obligaciones, por eso operaba por vía de excepción. Se partía de la base que había dos personas respectivamente deudora y acreedora una de la otra, de manera que los créditos se compensaban.

Se aplicaba ésta forma por acuerdo de las partes.

Se estableció que los banqueros –*argentarii*– podían compensar las deudas que tuviesen con sus clientes en la medida que estuviesen vencidas y fueran del mismo género, bajo pena de *plus petitio* en el caso de accionar judicialmente, o sea los banqueros podían perder el juicio.

El *bonorum emptor* también podía compensar los créditos, si su deudor era también acreedor suyo, siempre y cuando los créditos estuviesen vencidos.

Para que haya compensación eran necesarios ciertos requisitos:

1. Que sean obligaciones válidas y exigibles (exigible quiere decir que no se puede compensar una obligación a plazo con una obligación sin plazo o una obligación simple y pura con una obligación a condición.
2. que ninguna de ellas este sometida a otra condición.
3. tienen que ser liquidas o sea fungibles (dinero).
4. se tiene que tratar de sumas determinadas.
5. los créditos que se compensan tienen que ser homogéneos por ejemplo no se podía compensar un esclavo con un caballo porque son heterogéneos.
6. si de la compensación quedara algo restante deberá ser reintegrado ese excedente a la parte que corresponda.
7. la compensación siempre opera por la deuda de monto menor.

La *transactio*

Es el modo de extinguir las obligaciones dudosas o inciertas mediante recíprocas buenas predisposiciones que se hacen entre sí las partes. Celebran acuerdos para solucionar conflictos y no llevarlos a la vía judicial.

La transacción equivale a una sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada.

En la transacción hay concesiones o acuerdos entre recíprocos que realizan las partes para evitar situaciones dudosas o litigiosas.

La remisión de la deuda

Se realizaba a través de un *pactum de non petendo* – no reclamar-, que es el pacto por el cual el acreedor conviene con el deudor de no exigirle el cumplimiento de la obligación.

El *mutuo disenso*

Es cuando las partes que se obligaron por el mutuo consentimiento se desobligan manifestando la voluntad reciproca de extinguir la obligación.

Concurso de dos causas lucrativas

Se presenta cuando el acreedor recibe la prestación -objeto de la obligación- que se debe a título gratuito, también a título gratuito de parte de otra persona. Así por ejemplo si alguien se obliga a donarnos una cosa que luego nos dona efectivamente, se extingue la obligación del primer donante, porque el beneficiario ha recibido el objeto sin que le costara nada el objeto de la prestación. En cambio, si alguien se obliga a darnos y nosotros compramos la cosa, entonces la solución es distinta.

Modos de extinción del derecho pretoriano

En los modos de extinción *ope exceptionis*, estaban incluidas la *litis contestatio* en los *judicia imperio continentia*, la compensación *ex dispari causa*, en la compensación se le permitió al demandado oponer un crédito vencido, en las acciones de derecho estricto ya que había dolo al reclamar algo que ya había obligación de restituir), etc. También fue creación del pretor el pacto de demora – *pactum denon petendo*- era un acuerdo al que llegaban la partes, sin cumplir formas expresas o tácitas por la cual el acreedor renunciaba a la deuda en forma total o parcial, podía tener efectos *in rem* beneficiando a todos los acreedores o *in personam*: beneficiando a uno de ellos, quedaba extinguida la deuda si el pago perjudicaba al beneficiario. El deudor contaba con una *exceptio* de pago.

El proceso judicial privado romano

I. El procedimiento

Es un conjunto de reglas que se tienen que seguir para realizar un juicio en el que se reclama alguna pretensión cuando se ha lesionado un interés. Se busca obtener una reparación del daño sufrido. El procedimiento es dirigido por una autoridad judicial.

Estas reglas han tenido variaciones a través del tiempo, a continuación se desarrollarán las tres etapas históricas del proceso judicial privado romano.

Así se regulaba la actuación en la justicia, aspecto evolutivo y contrario a realizar justicia por propia mano.

En un proceso estaban presentes, el magistrado en un primer momento; luego intervenía el *iudex*, cuya figura se explicará en este capítulo, y las partes en conflicto: el actor o demandante y el demandado.

Los funcionarios judiciales

Eran los magistrados por un lado y los jueces por el otro. El primero preparaba la etapa *in iure*, no era etapa de juzgamiento; y el se-

gundo la etapa *apud iudicem* o in *iudicio* hasta el dictado de la sentencia, examinaba los hechos que se le planteaban para resolver. Había un listado de jueces –*iudex*–, al que se le asignaban temas particulares sobre los cuáles podían tener más dedicación.

El magistrado tiene la *jurisdictio* y el *imperium*.

La *jurisdictio* era la declaración del derecho de carácter general y para todos, por ejemplo: los edictos, mientras que la segunda comprendía el derecho de disponer de la fuerza pública para cumplir las órdenes.

La *jurisdictio* va unida a un cierto *imperium*. Hay de varias clases; por ejemplo, la jurisdicción contenciosa: se refiere a los litigios de los particulares, se ejercía en el territorio sobre el cual el tribunal tenía competencia;

La jurisdicción voluntaria: En ella no hay litigios, se puede solicitarla intervención por ejemplo para dar autenticidad a un acto como puede ser un testamento; podía ser ejercida en cualquier lugar.

Las cuestiones relacionadas con la jurisdicción civil se llama *imperium mixtum*.

Períodos

Los magistrados con potestades judiciales fueron variando a lo largo de los años:

Al principio la tuvieron los reyes y los cónsules.

En el siglo IV la tuvo el Pretor que se extendió cuando se creó la figura del pretor peregrino que abarcaba conflicto entre peregrinos o de éstos con los ciudadanos romanos. También los ediles que tenían competencia para ciertos casos, por ejemplo la venta de esclavos y animales.

En Italia la jurisdicción estaba a cargo de los *duumviri* y los *quatuorviri juridicundo*, a fines de la república se limitó su jurisdicción a los procesos a montos inferiores a quince mil sestercios.

La *jurisdictio* en las provincias estaba a cargo de los presidentes de ellas, luego se hizo extensiva a los procónsules, propretore, o legados del emperador. Los cuestores tenían un rol similar al de los ediles.

En la época del imperio aparecieron los magistrados llamados *praefecto* de la ciudad y del pretorio, asumiendo las funciones que en otros períodos estaban asignadas a los pretore. El territorio se dividió en cuatro prefecturas encabezados por un *praefecto* del pretorio, era el representante del Emperador, tenía un alto rango.

En las provincias estaban los defensores *civitates*, magistrados inferiores que juzgaban los asuntos de menor importancia.

El *Iudex*. Los *recuperatores*, centunviros y *decemviros*.

Un juez podía ser designado para cada asunto que lo terminaba resolviendo con el dictado de la sentencia. Acá podíamos encontrar a los *iudex* y a los *recuperatores*. También se llamaba *iudex* a los árbitros.

Sus diferencias eran

<i>Iudex</i>	<i>Arbiter</i>
Era siempre uno solo	Podía ser más de uno
Las cuestiones que debían resolver se basaban en el derecho estricto.	Los asuntos que resolvían se basaban en la buena fe.

Pero también había jueces que formaban tribunales permanentes.
Designación de los jueces

El pretor confeccionaba listas se las exponía en el foro y se los elegía a través de una elección. En el período de las *legisactionis* tenían rango senatorial, en tiempos de los Gracos fueron admitidos los caballeros. La edad mínima requerida para ser juez era de veinte años, era una carga pública y solo podía excusarse con causa justa.

Si las partes no se ponían de acuerdo se podía seleccionar a otro. Los *recuperatores* intervenían en los juicios entre ciudadanos y peregrinos.

Los tribunales permanentes estaban:

Los *decemviri stlitibus judiandis*, entendían en asuntos relacionados con la ciudad y la libertad.

Los *centumviri*, cada una de las 35 tribus nombraba a tres miembros y así el tribunal se componía de un total de 105 miembros. Luego el número fue elevado a 180. En el período del Bajo Imperio se dividieron en cuatro secciones llamadas *consilia*.

Los *triumviris capitales* entendían en las cuestiones en las que había que aplicar el sacramentum y la *manus iniectio*.

También abarcaban asuntos relacionados con persona, propiedad y sucesiones.

Estas figuras desaparecieron cuando apareció el procedimiento extraordinario.

Actio

Es la posibilidad de reclamar ante los tribunales.

También había otras formas de reclamos, por ejemplo los interdictos, la *in integrum restitutio*, etc.

Las acciones podían ser *in re* e *in personam*

Acciones civiles, provienen de la ley, senadoconsulto o constitución imperial	<i>In rem</i>	- <i>Reivindicatio</i> - <i>Actio negatoria</i> - <i>Actio confesoria</i> -Petición de herencia
	<i>In personam</i> , busca sancionar el incumplimiento.	-Obligaciones -Contrato -Cuasi contrato -Delitos - <i>condictio</i>

Honorarias o Pretorianas. Ejercidas por el magistrado en función de su <i>jurisdictio</i>, aplicaba el edicto o hacía extensión de las civiles para los casos que no estaban contemplados; y Edilicias	In rem	-Ficticias: <i>Publiciana</i> -In Factum: <i>Ius in agro vectigalis; quasi serviana</i> o <i>hyphotecaria</i>
	<i>In personam</i> Otorgadas por el pretor a quienes no podían ejercer la acción civil propiamente dicha.	- <i>Bonorum possessor</i> - <i>Bonorum emptor</i> - <i>Pauliana</i> - <i>Doli</i> - <i>Eo quod certo loco</i> - <i>pecuniae constitue</i> - <i>Iure iurande</i> - <i>Furtum manifestum</i> - <i>Vi Bonorum raptorum</i>

Las acciones directas se basan en la ley; las útiles fueron creadas para ser aplicadas por analogía, si no se podía aplicar se concedía una *actio in factum* basada en la equidad.

En las acciones de derecho estricto el *iudex* se ajustaba a lo establecido en la ley. En cambio en las de buena fe había un margen mayor de flexibilidad, teniendo en cuenta a la equidad y el caso en particular que había que resolver.

Extinción de las acciones

Podía ser por diferentes motivos, por transacción, por sentencia definitiva que cerraba la cuestión, por prescripción, por sufrir una *capitis deminutio* máxima. En lo que respecta a la muerte, el derecho tanto del acreedor como del deudor es transmisible por vía hereditaria. Si la muerte se produce antes de la *litis contestatio* eran transmisibles las provenientes del delito de injurias, la que se da para

revocar una *donatio inter vivos* por ingratitud del donatario y la que-
rella *inofficiosi* testamento.

Luego de la *litis contestatio*, todas las acciones se transmiten a los herederos del actor en contra de los herederos del demandado.

Las etapas procesales *in iure* e *in iudicio*

El proceso judicial comienza con la etapa *in iure*, se realizaba la *in ius vocatio*. Las partes se presentaban ante el magistrado, previamente el actor convocaba al demandado y si éste se negaba a concurrir ofrecía un *vindex* que era un garante de comprometiéndose a concurrir cuando sea citado judicialmente. En el caso de que no ofreciera garantía, el actor (demandante) en presencia de testigos lo podía intimar coactivamente a que concurriera, se lo autorizaba a actuar compulsivamente para hacerlo comparecer.

Una vez que las partes comparecían en presencia del magistrado celebraban el ritual correspondiente a la acción de la ley por la que accionan, sea el *sacramentum*, la *condictionem*, etc. Según lo establecido por una *Lex Pinaria* se designaba en el plazo de treinta días y las partes volvían a comparecer ante el magistrado dentro del tercer día.

Las partes ofrecían cauciones o garantías (*vades*) para asegurar su comparecencia.

El procedimiento se realizaba oralmente, justamente allí radicaba la forma a cumplir basados en la recitación de palabras solemnes que no podían ser erróneas, sino se perdía el juicio. Cerrada la primera etapa del proceso con un acto procesal llamado *litis contestatio*, terminaba la etapa *in iure* y se abría la etapa *in iudicio* a cargo del *iudex*. Manifestaban que pretendían y se discutían las cuestiones de hecho, excepcionalmente, de derecho. La sentencia era dictada, en la medida de lo posible el mismo día antes del anochecer.

II. Sistema de las *Legis Actionis* o acciones de La Ley

Ubicación Temporal: época clásica

Se denominó de ésta manera al sistema procesal que predominó en la época primitiva en que el derecho se encontraba bajo la influencia de lo religioso o fas.

La voluntad de los dioses requería del cumplimiento de formalidades sin las cuales los actos que se celebrasen no trascendían a la vida jurídica.

Período de la historia de Roma plagada de un excesivo rigor formalista. Los rituales se realizaban en la etapa *in iure*, el menor error en la recitación o en el cumplimiento de las formas se perdía el juicio; las partes debían concurrir personalmente, se celebraba los días *fastos*, había doscientos treinta y cinco días en los que se podían actuar y otros ciento treinta y cinco que no por las cosechas y las fiestas, de ésta regla quedaba exceptuada la *pignoris capionem*.

El conocimiento del derecho estaba a cargo de los patricios, estaba relegado el plebeyo. No se permitía la representación en juicios, o sea actuar en nombre de otro, pero había casos excepcionales como: *pro libértate*, en el caso de actuar en representación de un esclavo y la cuestión del litigio versa sobre su libertad; *ex lege hostilia*: era cuando un ciudadano que no se encontraba en la ciudad, por ejemplo estaba en las guerras y había sido víctima de *furtum*, otro en lugar de él podía ejercer la *actio furti*.

Se podía condenar o absolver, en el primer caso las condenas eran pecuniarias por lo general, había excepciones por ejemplo en la acción reivindicatoria el dueño de la cosa pedía en principio la devolución del objeto o cosa que es suya.

Según los asuntos a los cuales estaban destinados resolver tenemos, las siguientes cinco acciones: tres declarativas y dos ejecutivas.

Las acciones de la ley eran cinco: Tres declarativas y dos ejecutivas:

Legis actionem per sacramentum

Legis actionem per Iudicis postulationem arbitri

Legis actionem per condictionem

Las tres anteriores son declarativas

Legis actionem per manus iniunctionem

Legis actionem per pignoris capionem

Las dos restantes son ejecutivas

1) *Legis Actio per sacramentum*: Era de carácter Declarativo. Se caracterizaba por su carácter genérico al momento de plantear judicialmente el conflicto, respecto de aquellas situaciones en las que no estaba previsto como se tenía que litigar se recurría a ésta acción de la ley. Otras de sus características son las siguientes:

- a) Tenía montos pre- establecidos de 50 o 500 ases, llamados *sacramentum*, según el valor del litigio, era la forma en que se iniciaba la apuesta. Era destinado al culto de la parte que perdía.
- b) Las partes concurrían ante el magistrado.
- c) Simulaban una especie de combate con la vara o festuca, representaba la lanza utilizada por los romanos para ir a las guerras y apropiarse de las cosas del enemigo, en éste caso: tocaban con la festuca el objeto que se disputaban después de pronunciar palabras solemnes, era la lanza que usaban los romanos para apropiarse de las cosas.
- d) El demandante toma la cosa y afirma que es de su propiedad, luego hace lo mismo el demandado, tocándolo con la *festuca*, éste acto se llama *vindicatio*.
- e) Las partes se provocaban recíprocamente a la apuesta, se entregaba la suma apostada a los pontífices, con el paso del tiempo prestaban juramento de pagar en caso de que perdieran el juicio, se daban cauciones o garantías.
- f) La intervención del magistrado tenía carácter objetivo.

- g) Éste podía asignar la posesión interina de la cosa litigiosa hasta que se resolviera el asunto que se estaba tratando.
- h) Una de las partes se hacía cargo de cuidar y conservar la cosa objeto del litigio hasta que la sentencia resolviera a quién le pertenecía, debiendo el titular devolver los gastos realizados por quién antes la tuvo en su poder en concepto de gastos de cuidado y mantenimiento.

Si bien la cosa en conflicto siempre debía llevarse ante la presencia del magistrado, en relación a aquellas que ofrecían dificultades como las cosas inmuebles se podía llevar una parte de ella y se hacía la *vindicatio*, como si se hiciera por la totalidad de la cosa. La *vindicatio* era el acto por el cual se simulaba el combate ya referido en el que se pronunciaban palabras solemnes, y ninguna de las partes reconocía el derecho que alegaba la otra.

El que ganaba el proceso recuperaba la apuesta, y el que perdía su apuesta iba para el culto, con el paso del tiempo por disposiciones de la Ley *Papiria* va al *aerarium*.

- 2) *Legis Actio per Iudicis Postulationem Arbitr*: De carácter Declarativo. Se presume que es anterior a la Ley de las XII Tablas, se ampliaba el espectro de reclamos que en el *sacramentum* estaban muy limitados. Se incoaba ésta *actio* cuando los reclamos estaban originados en virtud de una *sponsio* o de una *stipulatio*, no se ejercían los rituales del *sacramentum*. Las partes se ponían de acuerdo para designar un tercero imparcial a ellas - *iudex o arbiter*- y así quedaba cerrada la etapa *iure iuris*. También servía para pedir la división de las cosas comunes (*actio communis dividundo*) o división de la herencia entre los co herederos. El *iudex* podía condenar por una suma dineraria o absolver.
- 3) *Legis Actio per Condictioem*: Era un acción de la Ley de carácter Declarativo. Se recurría a ella porque así lo establecía una *lex Silia*: en lo que se refiere a los reclamos de sumas

dinerarias; y la *Lex Calpurnia*, en cuanto a los reclamos de cosas ciertas. El actor intimaba al demandado a presentarse ante el magistrado en el plazo de treinta días, para elegir el *iudex*. El nombre de ésta *legis actio* proviene de *condicere* que significa a intimar, esa era justamente la intimación por el actor.

Hay poca información acerca de otras características de la misma. Se presume que con esta acción de la ley se quiso simplificar el proceso.

- 4) *Legis Actio per Manus Iniectio*: De carácter ejecutivo. La imposición de la *manus* se corresponde con una etapa del derecho primitiva, siendo una de las más antiguas que se conocían.

Tenía las siguientes características:

- a) Recaía sobre el deudor insolvente o confeso que había sido condenado en juicio a pagar.
- b) El acreedor lo llevaba a cárcel privada que en realidad era su casa, le restringía la libertad ambulatoria, hasta que pudiera venderlo durante los tres días de mercado.
- c) Antes de venderlo en el mercado podía aparecer un *vindex*, era una especie de garante, que pagaba la deuda que acreaba el deudor y lo liberaba de la situación en la que se encontraba.
- d) La restricción de la libertad ambulatoria no implicaba de modo alguno caer en esclavitud, ya que, desde el punto de vista jurídico no caía nunca en esclavitud aunque de hecho recibiera un trato de tal.
- e) Si un *vindex* pagaba la deuda, el rescatado debía devolverle lo que hubiere pagado por él, caso contrario se le podía imponer nuevamente la *manus iniectio*.
- f) Si perdía el juicio debía pagar el doble por accionar sin derecho.

Esta acción de la ley se hizo extensiva a otras situaciones que fueron apareciendo con el tiempo, como las siguientes:

- 1) El prestamista que había cobrado de más, de acuerdo a lo estipulado por las leyes que regían la usura, tenía la obligación de devolver todo aquello que hubiere recibido de más caso contrario, se imponía sobre él la *manusiniectio*. Así lo disponía la Ley Marcia.
- 2) La Ley Furia Testamentaria prohibía que una persona recibiera por legado más de mil ases, de modo que para aquellos que burlaran la ley e hicieran varios legados de más de mil ases a la misma persona, quién los recibiera debía devolver el excedente sino se imponía sobre ella la *manus iniectio*.
- 5) *Legis Actio per Pignoris Capionem*: De carácter ejecutivo. Si bien se ubica históricamente en una etapa antigua en la que el derecho se hallaba bajo la influencia de lo religioso o fas, parece marcar una especie de transición hacia la conversión del derecho religioso en laico muy paulatinamente. De ésta manera va presentando caracteres particulares que además de diferenciarlo de los anteriores por sus particularidades se evidencia la incipiente desformalización, siendo sus características las siguientes:
 - a) Se podía tomar en *pignus* (prenda) informalmente la paga destinada a los militares cuando quién tenía obligación de hacerlo no lo había realizado.
 - b) También usaba ésta forma para tomar el dinero obtenido contra aquel que hubiera comprado un animal para sacrificarlo a los dioses y no pagara el precio; de igual manera contra el que no entregase el alquiler de una caballería siempre que el dinero de tal alquiler se hubiera destinado para realizar una ofrenda¹¹.

11 *Lege autem introducta est pignoris capio, veluti lege XII tab. adversus eum, qui hostiam emisset nec pretium redderet ; item adversus eum, qui mercedem non*

Ésta última acción de la ley tenía caracteres muy peculiares, por los cuales hay quienes piensan que se trataba de una acción que se corresponde con una etapa histórica en la que se produce una transición hacia el procedimiento formulario. Sus caracteres eran:

- a) la falta de exigencia de rituales solemnes
- b) se podían llevar a cabo tanto los días fastos como nefastos.
- c) No era necesaria la presencia del magistrado ni de testigos.
- d) Se podía hacer de día o de noche.

El Procedimiento Formulario

La Transición

El paso del sistema de las *legis actionis* al procedimiento formulario no fue de un momento a otro sino que en un momento dado coexistieron ambos sistemas, pero han influido diferentes factores que hicieron que se deje de lado el uso de un sistema para empezar a utilizarse otro, los factores fueron:

- 1) El excesivo rigor formal que se exigía para llevar a cabo el procedimiento: el menor error material o jurídico hacía perder el litigio a quién hubiese incurrido en él, no importaba si era el que tenía la razón;
- 2) Perdido el juicio no se volvía nunca más sobre el asunto;
- 3) Se corresponde a una etapa histórica en la que empieza a destacarse la labor del Pretor (año 242 a.C.), que buscaba solucionar conflictos entre peregrinos a los que les estaba vedado el uso del procedimiento de las *legis actionis*;
- 4) Empiezan los procesos judiciales entre ciudadanos romanos y peregrinos, el sistema de las *legis actionis* ya no se podía aplicar porque estaba reservado a los ciudadanos romanos.

redderet pro eo iumentum, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, impenderet (Gaius, 4, 28 ; Cf. Fest., Daps ; Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 2).

- 5) Si bien en el año 130 a.C. la *Lex Aebutia* abolió el sistema de las *legis actionis*, también se presume que empezó por abolir la *condictio*. Las *legis actionis* permanecieron en vigencia para aplicarse en los casos del *damnum infecti*, y los procesos entablados ante el Tribunal de los centunviros; pero con el paso del tiempo cayó en desuso por los motivos explicados.

Clasificación de las Fórmulas:

- a) Fórmulas que tienen una *intentio in ius concepta* –es la *intentio* que se basa en derecho-. El magistrado empieza a contemplar determinadas situaciones amparándose en el derecho que antes no estaban contempladas, como eran las *praescriptiones* y las *exceptiones*.
- b) Fórmulas ficticias: Son aquéllas en las que se ordena al *iudex* que deje de lado considerar la existencia o inexistencia de una circunstancia o condición de la sentencia que va a dictar, por ejemplo: Un ejemplo a propósito de la propiedad bonitaria: “Cornelio, sé juez, si Aulo Agerio compró y le fue entregado (sin *mancipatio*) el esclavo Sticho, que, si lo hubiera poseído un año, sería suyo según el *ius quiritium*, y a pesar de tu decisión, Numerio Negidio no lo hubiera restituido a Aulio Agerio, condena a Numerio Negidio, a pagar a Aulio Agerio tanto dinero como valga la cosa, y si no ha resultado así Absuévelo”. Aulo Agerio no ha tenido un año de posesión para poder llegar por *usucapio* a ser dueño del esclavo, pero se le indica al juez que asuma ficticiamente que ha tenido lugar ese lapso y discrimine, en cambio, las otras condiciones que posibilitan la *usucapio*.

- c) **Fórmulas Útiles:** Son aquellas que hacen extensivas determinadas situaciones al derecho civil cuando en otros tiempos no estaban comprendidas, por ejemplo la posibilidad que tenía el *bonorum emptor* de ejercer las acciones útiles que se relacionaran con el patrimonio adquirido.
- d) **Fórmulas con Transposición de sujetos:** Se utilizaba para superar determinadas situaciones que en otros tiempos no estaban comprendidas, por ejemplo: si se quería demandar al *filius* en virtud de su peculio su responsabilidad solo operaba hasta el monto de éste, sin embargo con esta clase de fórmulas se lo podía demandar al *pater* ya que su nombre era colocado en la *condemnatio*, mientras que el nombre del *filius* era colocado en la *intentio*.
- e) **Fórmulas *in factum conceptae*** –se basaban en situaciones de hecho–por lo tanto al no estar contempladas en el derecho el pretor les daba protección. Según los casos podía dictar un edicto repentino.

Partes de la Fórmula

- a) **Demonstratio:** Era la parte de la formula en la que se manifestaba cual era el objeto del litigio: por ejemplo, Ticio reclamaba el fundo Tusculano.
- b) **Intentio:** Era la parte en la que manifestaba cuál era la pretensión jurídica del actor: Por ejemplo: reclamar al esclavo que se adeudaba en virtud de una compra venta; para hacer un reclamo debía existir un título jurídico que avale o respalde lo reclamado en juicio, ya que no se trataban de un capricho del actor de reclamar algo porque sí.

Encontrábamos distintas clases de intentio:

- 1) ***Intentio certa*:** El objeto es especificado, es determinado, no hay lugar a dudas de lo que se reclama.

- ma, no se trata de algo genérico.
- 2) *Intentio incerta*: El objeto aún no está determinado, será determinado posteriormente por decisión judicial.
 - 3) *Intentio in ius concepta*: cuando el ejercicio de la acción nace del *iuscivile*.
 - 4) *intentio in factum concepta*: Se trata de una situación de hecho que va a gozar de protección por parte del pretor.
 - 5) *Intentio in personam*, cuando el reclamo iba dirigido a un deudor determinado.
 - 6) *Intentio in rem*: para reclamar una cosa.
- 1) La *intentio*: Resulta que si se trata de una *intentio* en la que el objeto de reclamo debe ser especificado, se puede incurrir en una *plus petitio*, ésta podía ser de varias clases:
- f) *Plus petitio re*: Era cuando se reclamaba un objeto diferente del que se tendría que haber pedido, o en el caso de cosas en cantidad se pedía de más, o de menos, en realidad se pedía de un modo diferente del que se tendría que haber hecho, en otras palabras el pedido estaba mal hecho.
 - g) *Plus Petitio Tempore*: Era cuando se reclamaba algo en un tiempo que no correspondía: podía ocurrir de dos modos: que se reclame algo sin haber fecha de vencimiento del negocio jurídico, pero la naturaleza de la prestación aún no hacía exigible su cumplimiento: por ejemplo que la prestación objeto del negocio consistiera en la entrega de un becerro sometido a condición, de que se produzca su nacimiento, y el acreedor lo exige cuando aún no se produjo éste hecho; también puede ocurrir cuando estando sometido el negocio jurídico a fecha de vencimiento o plazo, éste aún no haya operado y el

acreedor exija su cumplimiento, lo que deberá ser neutralizado por el deudor a través de una *exceptio*.

- h) *Plus Petitio Loco*: Cuando se celebra un negocio jurídico se establece por lo general el lugar (loco) donde se va a cumplir con la prestación, pero en algunos casos ésta cuestión no está preestablecida, entonces la ley determina que la prestación deberá ser cumplida en el domicilio del deudor o en el lugar donde se encuentre la cosa, si nada se acordó. Se incurre en *plus petitio* cuando se reclama la cosa en un lugar que no fue el acordado por las partes, o que por la naturaleza de la prestación no era el lugar donde debía exigirse su cumplimiento y lo puede perjudicar de algún modo al deudor.
- i) *Plus Petitio Causa*: Es cuando se invoca una causa jurídica diferente de la que se tendría que haber manifestado como otro de los fundamentos de la realización del negocio jurídico. Por ejemplo reclamo al esclavo por haber celebrado una compraventa pero resulta que me lo deben por una donación, la causa jurídica que legitima el negocio no es la que debía invocarse por lo tanto se ha incurrido en *plus petitio*.

La consecuencia de la *plus petitio* es que hace decaer el derecho de quién la comete (caducidad) además se le imponen costas al que incurre en alguna de ellas.

- c) *Condemnatio*: En ella se manifestaba que era lo que el actor pretendía se establezca en la sentencia: la absolución y la condena, se pedían las dos cosas: “Te pido que condenes a Varrón a que me devuelva el esclavo, si no fuera así absuévelo”, el sentido radica en que si el demandado no era culpable correspondía judicialmente su absolución, se trataba

de una cuestión formal, no plasmaba la intención del actor que siempre manifestaba tener la razón y no admitía perder el juicio. En caso de tratarse de una condena ésta se podía tratar de la devolución de la cosa reclamada: por ejemplo un esclavo; el pago de una suma dineraria *certa*: dos mil ses-tercios; o en el caso de que el objeto fuera *incerto*: su deter-minación se hacía en base a una litis *aestimatio*; sin dejar de tener en cuenta que si celebraba una *estipulatio* adicional al momento de ser condenado debía pagar una suma más alta.

- d) *Adjudicatio*: Dependía de la naturaleza de la cosa objeto del litigio: para evitar el deterioro o la extinción del objeto, por ejemplo evitar la muerte de animales o esclavos por falta de alimentos hacía que, hasta que se resolviera el conflicto al-guna de las partes se hiciera cargo de poseer interinamente la cosa hasta que se dicte sentencia que determinara quién debía hacerse cargo por derecho de ella, en ese caso debía devolver a quién la tenía a su cargo todos los gastos que hu-biere realizado para el cuidado y conservación de la cosa¹².

No se cumplía a rajatabla la existencia de todas las partes de la fórmula tal cual como se acaba de describir, en algunos casos alguna podía no hallarse porque la exigencia de la prestación no la requería.

Las Excepciones

Son medios de defensa que esgrime el demandado con diversos fines: puede ser para detener provisoriamente la continuidad del pro-ceso o para hacerlo finalizar definitivamente cualquiera sea el estado en el que se halle.

Las primeras se denominan excepciones dilatorias: el demandado opone su medio de defensa cuando se dan determinadas caracterís-ticas por las cuales considera desde el punto de vista jurídico que en

12 Otro caso de posesión interina de la cosa objeto de un litigio, era en la bonorum possessio, por la cual el pretor podía otorgar la posesión interina de la cosa litigiosa en favor del presunto heredero hasta que se resolviera el asunto.

ese momento no debe prosperar un juicio en su contra, impide su prosecución transitoriamente, una vez que se produzca una situación permita seguir con el proceso éste continuará: por ejemplo: el actor le reclama el pago del precio de la locación, pero ocurre, que no ha vencido el plazo para hacer efectivo el pago, por lo tanto hasta que el mismo no opere el actor no está habilitado para reclamarle.

Las segundas se denominan Excepciones Perentorias: La mismas tiene por objeto hacer caer definitivamente el proceso, porque se dan situaciones por la cuales el juicio no puede prosperar, por ejemplo: el actor exige la entrega de una cosa y la misma ya se realizó, cuando se reclama a alguien distinto de quién tendría que haber sido el demandado, o cuando hubo un *pactum de non petendo* (pacto de no reclamar) y el actor reclama igual el cumplimiento de la prestación, independientemente de que el actor opere con negligencia o malicia.

Oportunidad procesal

La oportunidad procesal para presentarla es luego de la *intentio* a pedido del demandado y los efectos una vez probada la *exceptio* pueden ser una condena leve o la absolución del demandado.

Las Réplicas

Así como el actor interpone una demanda y el demandado opone una *exceptio*, el actor en contra de la *exceptio* hace una *replicatio* posibilidad que también tendrá el demandado de contestarle por medio de otra *replicatio*.

La Praescriptio

Se colocaba al redactar la fórmula, podía ser establecida den favor del actor o del demandado, según el caso. Era como especies de reservas que se hacían para evitar los efectos de la litis *contestatio* le hiciera perder el juicio a la parte que la invocaba.

Cuando era un *praescriptio pro actore*: Por ejemplo: si el actor reclamaba una suma de dinero en concepto de alquileres impagos debía dejarse salvaguardada la posibilidad de reclamar en el futuro las sumas que se devengasen y que estuvieren impagas, se aclaraba que se accionaba por lo adeudado hasta ese momento, si no lo hacía podía perder el juicio por hacer un relamo genérico que incluiría tácitamente todo lo que comprenda el contrato de alquiler, ese es el motivo de la *praescriptio*, evitar esto.

Cuando era una *praescriptio pro reo* (para el demandado), se tratan de medios de defensa y pueden ser por ejemplo la *praescriptio longi temporis*; había otras denominadas prejudiciales en la que se establecía que el *iudex* debía resolver sobre una cuestión para prejuzgar otra más importante.

Comienzo de la etapa in iure

- 1) Se podía dar aviso al demandado extraoficialmente;
- 2) Luego se hacía la *in ius vocatio*: se lo citaba al demandado para que comparezca;
- 3) El demandado garantizaba su participación en el juicio a través de una *stipulatio*, también se comprometía por otra *stipulatio* a cumplir la condena.
- 4) El demandado se comprometía a no actuar con dolo;
- 5) Si no cumplía con ninguno de los pasos referidos, el pretor estaba habilitado a vender su patrimonio¹³.
- 6) Para el caso de que, las partes se presenten ante el magistrado, el actor solicita la acción;
- 7) El pretor verifica la legitimación de las partes para actuar en el proceso;
- 8) También verifica si son cuestiones contempladas en la ley, para el caso de que existiere sobre el asunto planteado algún vacío legal, el magistrado concedía la *actio in factum*;

13 D.50,17,52.

- 9) El magistrado podía denegar el ejercicio de la acción.
- 10) En el caso de que lo admitiera, les pedía a las partes que lleguen a un acuerdo para evitar la etapa judicial, buscando una solución más rápida y efectiva, se hacía una *transactio*, se trata de un remedio jurídico que evitaba llevar a cabo un juicio tedioso y largo, quizá con un resultado hasta más perjudicial si se quiere que el que se pudiera conseguir por medio de una sentencia, es una herramienta aconsejada y utilizada en el derecho actual.
- 11) Podía ocurrir que el demandado aceptara las pretensiones del actor, significa que se ha allanado a la demanda y se lo tiene por *confessus*.
- 12) Si las partes no se ponían de acuerdo se designaba a un *iudex*, *recuperatores* o colegio judicial.
- 13) El *iudex* era elegido por las partes o por el magistrado de un listado que existía previamente.

La Litis Contestatio

Tuvo diferentes significados según la evolución histórica, durante el sistema de las *legis actionis*, aquí se hacía la comprobación de la cuestiones de hecho por medio de aspectos jurídicos como era la producción de la prueba.

En la etapa del procedimiento formulario la etapa *in iure* o primer etapa quedaba cerrada cuando se trababa la *litis contestatio*, así se denominaba al decreto del magistrado en el que quedaba planteado el conflicto ya que el actor había manifestado sus pretensiones y el demandado se había opuesto a través de excepciones, se abría la etapa *apud iudicem in indicio*, quedaba perfectamente establecido sobre qué debía expedirse el *iudex* en su sentencia.

Con ella la antigua obligación del demandado queda extinguida y aparece una nueva, por ese motivo se produce una *novatio* necesaria: debe continuar el proceso y hacerse cargo de la condena en caso de que ello ocurra. Quedan subsistentes las prendas, hipotecas y privile-

gios sobre os créditos, Los intereses siguen su curso normal, A diferencia de la novación necesaria en la que no se dan éstas cuestiones.

Para que opere ésta novación forzosa, el proceso tiene que ser un *iudicium legitimum* o sea ante ciudadano y un *iudex*; que la fórmula haya sido concedida *in ius* (en derecho).

La nueva obligación que nace es civil y perpetua además de transmisible. Por otro lado, las partes que intervienen en el juicio no pueden cambiarse (a diferencia de una novación voluntaria en la que puede cambiarse las personas del deudor y del acreedor).

El *iudex* va a resolver en base a lo fijado a la *litis contestatio*.

La *litis contestatio* acarrea consecuencias para las partes: ambas quedaban obligadas a continuar el proceso hasta el final; la cosa litigiosa no podía ser objeto de acto jurídico alguno; cuando operaba la extinción de la acción de la misma manera que en el procedimiento de las *legisactionis* ya no se volvía sobre el asunto: es el precedente de nuestro principio constitucional *ne bis in idem*.

El procedimiento en la etapa *Apud Iudicem* o *in iudicio*

El procedimiento se dividía en dos etapas, como en el sistema anterior.

Se denominaba de ésta manera por la sencilla razón de que se redactaban por escrito formulas. Las partes de las mismas eran las siguientes:

En la etapa *in iure*, se hacía la *in ius vocatio*, comparecían las partes ante el magistrado, si una de ellas no lo hacía y tampoco otorgaba un *vinde*, se le podía imponer una multa.

El demandado podía pedir la *denuntiatio litis* que era una notificación en el que se tenía que indicar cuál era el objeto de la demanda y el día en que había que comparecer ante el magistrado.

Luego el actor establece cuál es la *actio* que va a ejercer, se realiza, luego, un debate en el que se va a discutir sobre si se otorga o no la *actio* y también sobre la redacción de la fórmula. A veces podía suceder que no se le otorgue la *actio* al actor debido a que el demandado recono-

ce la existencia del reclamo que se le hace y se lo considera *iudicato*, en dónde cumplía con el reclamo dinerario si fura ese; caso contrario el proceso seguía hasta ser condenado, cuando el demandante no en-contraban una acción contemplada en el edicto; también cuando el demandado tiene una *exceptio* para oponer y la puede probar en la etapa in iure, etc.

Luego se pasa a la redacción de la fórmula. Antes de redactar sus partes se ponía el nombre del *iudex* que en el futuro se iba a hacer cargo del asunto. Se presenta la misma al demandado y éste la acepta cerrándose el procedimiento in iure. Si se niega se expone a sanciones pecuniarias.

Así se cerraba ésta etapa con la *litis contestatio*.

Tenía las siguientes características:

- a) se realizaba ante el *iudex* o conjunto de iudex designados al efecto.
- b) El mismo debía prestar juramento de que iba a tener un desempeño objetivo en los asuntos que les encomendaban.
- c) Si no fuera así debían excusarse¹⁴
- d) A partir de que prestaban juramento se convertía en una carga pública y no podían negarse a expedirse en el asunto que se le confiaba salvo causa justificada.
- e) La audiencia debía realizarse desde la salida hasta la puesta del sol,
- f) Los aplazamientos no debían ser muy extensos.
- g) Se realizaba la *coniectio causae* de la misma manera que se hacía en el sistema de las *legis actiones*.
- h) La aparición de los *oratores* en el proceso obedece a que había que poner a alguien que defendiese el interés de las partes en un proceso contradictorio, éste si bien no era un instruido en derecho, su habilidad estaba en esgrimir argumentos basados en las pruebas, y tratar de convencer al *iudex* de que

14 D.50,5,13.

su cliente tenía la razón independientemente de que fuera verdad o no o que alegara. Cicerón fue un gran maestro en el arte de la oratoria, y quién empezó su carrera política como un gran orador fue julio César en su juventud.

- i) Los medios de prueba que se podían invocar eran: los testigos, documentos (se diferenciaban entre instrumenta pública e instrumenta privada), la confesión: que era una declaración jurada del actor que se hacía bajo juramento.
- j) Luego de los alegatos se dictaba sentencia: En principio inapelable, luego se podía apelar ante la autoridad del emperador. La misma era confirmada, modificada o anulada;
- k) El condenado debía cumplirla en el plazo de treinta días¹⁵. Caso contrario el vencido ejercerá en su contra la *actio iudicati* con el fin de que el condenado ejerza su derecho de defensa y pruebe que cumplió con la disposición judicial, si vuelve a perder será condenado por el doble. Además su patrimonio será ejecutado.

Legitimación para actuar en el proceso

Legitimación Activa

- a) El pater ya que era un *sui iuris*;
- b) El filius hasta el límite de su peculio si se trata del castrense;
- c) El filius podía ejercer la acción por injuria;
- d) La filia podía ejercer la *actio rei uxoriae*; con el fin de obtener la devolución de la dote.

Legitimación Pasiva

- a) El *pater*.
- b) Los *alieni iuris*, pero para la ejecución de la sentencia había que esperar a que sean *sui iuris* dado que no tenían patrimo-

15 Dispuesto de ésta manera por la Ley de las XII Tablas.

nio propio; la otra posibilidad era demandar al *pater* mientras el *filius* estuviera bajo su *potestas*; o en el caso de que se demande solo al *filius* éste respondía hasta donde el monto del peculio se lo permitiese.

Debemos recordar que los esclavos no eran en ningún caso demandables, al que se demandaba era a su *pater* o amo.

Intervención dentro del Proceso: Formas de Intervenir

Las partes podían actuar personalmente o por medio de representantes, que sustituían a las partes en los efectos del juicio, así el deudor era demandado pero en la *condemnatio* se ponía a otra persona que era quién iba a soportar los efectos de lo que resolviera el *iudex*, se hacía a través de la *actioiudicati*¹⁶.

Las partes podían ser sustituidas o representadas por el *cognitor* o por el procurador:

El Cognitor

Es un representante que se nombra en presencia del contrario en el juicio; cuando representa al actor éste ya no puede incoar nuevamente la acción y lo que se resuelva en relación a la ejecución va a ser a su favor.

El Procurador

En cambio a diferencia del anterior los efectos de la sustitución del actor no son los mismos: no extingue la acción y no fue nombrado en presencia del adversario cumpliendo las formalidades, el procurador garantiza que con su intervención el actor va a cumplir con lo dispuesto por la sentencia y que no va a pretender ejercerla nuevamente en el futuro, ello lo hace a través de la garantía llamada *cautio dominum rem ratam habiturum* (caución por la que el dueño ratificará el negocio).

16 Sin embargo el Pretor en la *condemnatio* siempre ponía al involucrado y no al sustituyente.

Si el demandado es representado, por un *cognitor* o *procurator*, la acción queda extinguida, la consecuencia que acarrea es que no podrá ser intentada de nuevo por el actor, pero en lo que respecta a la acción ejecutiva se ejercerá en contra del demandado cuando es representado por *cognitor*, pero, se va a dirigir en contra el representante si éste es un *procurator*. De manera similar opera la *cautio iudicatum solvi* que se le otorga al demandado representado por un *cognitor*, pero si el representante es un *procurator*, éste la otorgará a éste.

La sentencia

Después de los alegatos realizados por los *oratores*. El *iudex* dictaba sentencia. La misma podía versar sobre:

- 1) Condenar: a restituir la cosa, a dar cantidades ciertas, también imponer multas a los litigantes temerarios y recalcitrantes, éstos últimos eran aquellos que negaban el derecho del triunfador en el proceso a pesar de haber sido condenados. En el caso de los poseedores de mala fe deben además los frutos de la cosa.
- 2) Absolver.

Ejecución

El condenado tenía un plazo de sesenta días para cumplir con la misma. En los primeros tiempos se aplicaban la *manusiniectio* y la *pignoris capionem*: En la época del procedimiento formulario se aplicaba la *bonorum venditio* entre otras formas de ejecución del patrimonio del deudor insolvente.

El Procedimiento *Extra Ordinem Cognitum*

Introducción

Ubicación Temporal: Durante la época del imperio hasta tiempos de Justiniano.

Características:

- 1) El procedimiento formulario fue abolido con una Constitución imperial del año 342¹⁷.
- 2) A diferencia de los sistemas anteriores aquí hay una intervención del Estado directa ya que administra justicia un funcionario público en su representación, se dejan los iudex privados.
- 3) Se empieza a implementar de manera lenta y progresiva primero en las provincias, luego en Italia y finalmente en Roma.
- 4) Se corresponde con una etapa histórica en la que Diocleciano (bajo Imperio) produce una centralización política y administrativa que va a repercutir en la administración de justicia.
- 5) En el “*Alto Imperio*” o “*Principado*”, (derecho clásico-siglos I a III D.C.) la justicia civil estuvo a cargo (al igual que en la República) por magistrados electivos e independientes como los pretores, urbano y peregrino y los ediles curules en Roma, por los “*praefecti iure dicundo*” y los magistrados municipales en Italia y por los gobernadores en las provincias.
- 6) Durante el *Bajo Imperio*”, esto cambió, los órganos a quienes se encomienda la administración de justicia son funcionarios designados por el emperador, que actúan en nombre de éste, en quien reside la suprema potestad judicial y están jerarquizados, lo que a su vez va a permitir, la instancia procesal denominada *apelación* ante el órgano que será de grado superior en relación a las sentencias pronunciadas por un juez de grado inferior, se buscaba la modificación de la sentencia que se consideraba agravante.
- 7) El proceso ya no se dividía en dos partes como en el procedimiento formulario y en el sistema de las *legis actionis*.
- 8) Hay una sola etapa que se realiza ente el *iudex* que se constituye

17 En el período clásico con la desaparición de las magistraturas, entre ellas la pretura, favoreció la absorción del poder por parte del emperador quién se encargó de la administración de justicia delegando posteriormente en funcionarios de rango imperial.

en un funcionario, integra un órgano que pertenece a la esfera administrativa del Estado.

- 9) La citación ya no está a cargo del demandado y se transforma en una orden que proviene de un funcionario público.
- 10) Se realiza un *libellus denuntiationis* en la *litis denuntiatio*, es examinado por el *iudex* y se le avisaba al demandado de su existencia a los efectos de que, en un término que no superen los cuatro meses lo conteste por medio de un *libellus contradictorius*.
- 11) Las partes se presentaban a una audiencia en las que se exponían las distintas posturas era la *litis contestatio*.

Clasificación de los jueces

Pueden distinguirse entre los jueces de este período los superiores de los *ordinarii*, los *pedanei* y los *locales*.

- a) Con relación a las *minores causae*, tenían competencia *duumviri iure dicundo*, en tiempos del *Bajo Imperio*, la competencia la tiene otro funcionario municipal, llamado *defensor civitatis*. En casos excepcionales se recurría al Gobernador de Provincia.
- b) En las *mayores causae*, que eran aquellas causas que excedían de un determinado monto tenía obligación de actuar el Gobernador, dado que delegaba en funcionarios llamados *iudices pedanei*, así llamados porque permanecían de pie ante el magistrado que estaba sentado en su estrado.
- c) Luego seguían en el escalafón los *iudices ordinarii* que tenían competencia general para toda clase de asuntos.
En Roma y Constantinopla encontrábamos:
 - 1) A los *praefecti urbi* (prefectos de la ciudad) que sustituyeron al pretor urbano en la administración de la justicia civil.
 - 2) Permanecieron durante algún tiempo los pretores especiales del Alto Imperio, como el *pretor tutelaris*, el

que entendía en el cumplimiento de los *fideicomisos*, el de las “causas liberales”, etc.

- 3) En las provincias actúan como *iudices ordinarii* los rectores o *praesides*, o sea los gobernadores.
 - 4) Luego en tiempos de Diocleciano aumentó el número de provincias, con otra estructura el gobernador no tuvo, que recorrerlos periódicamente para realizar sesiones –*conventus*– se hacían en el lugar en el que residían. Debido a la gran cantidad de asuntos que se presentaban y que en teoría debían atender es que, delegan en otros funcionarios la administración de justicia, abarcaba sus competencias solo para las *minores causae*, o sea los asuntos de menor cuantía económica.
- d) En el escalafón más alto de la administración de justicia estaba el Imperator, si bien estaba en su competencia sentenciar en primera y en única instancia, por medio de la *advocatio*, que les permitía atraer hacia sí cualquier asunto de que esté conociendo un juez inferior cuya competencia se considera simplemente delegada por ellos era una excepción, la regla era que su intervención se reservaba a la revisión de un fallo judicial, como última instancia.
- e) Además del emperador estaban entre los jueces superiores, como consecuencia de la división del imperio en prefecturas:
- a) Los *praefecti praetorio*: Sus decisiones judiciales no eran apelables porque ellos mismos eran los representantes del emperador, caso contrario sería una doble apelación ante la misma instancia superior.
 - b) Los *vicarii*, que estaban al frente de las diócesis, contra cuyas sentencias podía apelarse ante el emperador.

La *cognitio extraordinaria* fue aplicada en tiempos de Augusto por algunos funcionarios administrativos, como los *praefecti aerario*, *annonae*, *vigilum*, etc.

El Procedimiento extra-ordinem, caracteres

La intervención judicial a cargo de los gobernadores ya sea directamente o por medio de funcionarios delegados, se venía aplicando desde hacía mucho tiempo. Algunas cuestiones se resolvían por medio de la *cognitio extra ordinem*, cuando se publica la Constitución de Diocleciano y Maximiano del año 294 (Cod. III, 3, 2) en virtud de la cual se autorizó a los gobernadores de provincias para conocer en las causas que anteriormente debían necesariamente remitir a los *iudices pedanei*, sin perjuicio de delegar la función cuando lo estimaran conveniente.

El proceso extraordinario ofrece características propias, que permiten distinguirlo del formulario de la época clásica.

- a) No era necesario que esté presente el demandado en el proceso, era contumaz, el proceso igual continuaba aunque él no concurriera.
- b) Se produce una modificación en cuanto a las reglas de competencia, las controversias sobre inmuebles podían ser juzgadas por jueces del lugar donde se halle la cosa litigiosa, no necesariamente tenía que ser el juez del domicilio del demandado.
- c) La nueva forma de citación del demandado, que no lo será ya la *in ius vocatio* del proceso antiguo y clásico, sino que podrá serlo, según las épocas, el de la *denuntiatio apud acta* o el del *libellus conventionis*.
- d) Se modifican los efectos de la *litis contestatio*, no va a provocar como ocurría en el procedimiento formulario, la extinción de la acción deducida en juicio.
- e) También se producía una modificación en lo referente a la *plus petitio* y sus efectos dado que por incurrir en ella no

se perdía el pleito, podía haber sanciones penales en el caso de la *plus petitio re o tempore*, pagaba una suma dineraria y cargaba con las costas del proceso además debía esperar el doble de tiempo para volver a litigar.

- f) Se exigió que la sentencia solo fuera leída en público, bajo sanción de nulidad debían estar presentes las partes y el juez.
- g) De a poco la mayor parte del proceso se va haciendo escrito cuando en el procedimiento formulario solo era escrita la fórmula.
- h) La mayor *onerosidad* del nuevo proceso, que obliga a los litigantes a cargar con ciertos gastos de justicia –*sportulae*– como las sumas que se pagan a los abogados (en realidad la cuestión de pagarle a los abogados va pasando por distintas evoluciones de las cuales se hace una breve referencia más adelante), cuya intervención es necesaria, los oficiales del juez, por ejemplo. A este respecto se estableció en una Constitución de Zenón (Cód. VII, 51, 5) que el juez en su sentencia ordenaría al vencido el pago de todas las costas del juicio, que podrían ser incrementadas en una décima parte si obrara con temeridad.
- i) La condena: Podía consistir en :
 - 1) En la entrega de una cosa a quién hubiere ganado el juicio, se podía recurrir al auxilio de la fuerza pública para obtenerla.
 - j) Si consiste en una suma de dinero que no se abona, se tomaban en *pignus* bienes muebles de modo con el fin de garantizar el pago para su posterior venta y cobro de la deuda.
 - k) En cuanto a los plazos, desaparecen las reglas que establecían como duración máxima del proceso el de dieciocho meses en lo que respecta a los *iudicialégítima* y el tiempo que duren los poderes del magistrado en el caso de los *imperio continentia*;
 - l) Se dispuso por una *lex properandum* que cualquier proceso civil con excepción de los referidos a las funciones públicas o al derecho fiscal no podían extenderse más de tres años desde la *litis contestatio*.

Como se desarrollaba el Proceso

A. La *litis denuntiatio*, es la citación del demandado, el actor comparece ante el juez a quien se lo pone en conocimiento de la existencia de la demanda en su contra, que se registra *apud* acta en su oficina, autorizando éste la citación del *reus –litis denuntiatio-* que en la primera época se llevó a cabo personalmente por el demandante en presencia de testigos, y a partir del siglo IV con intervención de un funcionario provisto del *ius acta conficiendo* (Const. De Constantino del año 322 y de Teodosio del 424, incluidas ambas en el Código Teodosiano, II, 4, 2 y IV, 14, 1

Cuando el demandado es citado a juicio, tiene un plazo de cuatro meses para comparecer ante el juez, su no lo hace continuará el procedimiento en carácter de contumaz (rebelde).

En tiempos de Teodosio, se podía realizar un procedimiento sumario, sin *denuntiatio*, ni los plazos ordinarios, para casos especiales, particularmente el de los créditos procedentes de préstamos en dinero o el de los compromisos contraídos por escrito.

1. El procedimiento por *Libellus*: Desde el siglo V el procedimiento por libelo (escrito), que si bien se realizaba para determinados casos en el período clásico por una Constitución de Zenón (período de Justiniano) se extiende como regla general esta forma de citación. La misma comprende:

- a) El *libellus conventionis* o de demanda, es un escrito redactado por el “actor” o sus consejeros en el que hace una exposición sumaria de los términos de la demanda, que se entrega al juez, pidiendo que se cite al demandado.

El juez entonces, va a examinar el libelo y si lo considere procedente le va a dar curso, a través de un auxiliar denominado *executor* lo cita al demandado por medio de una *conventio*.

- b) El *libellus contradictionis* o de defensa, que presenta el demandado ante el juez dentro del plazo de

diez días al principio y de veinte después, cuando tomaba conocimiento del *libellus conventionis* debía otorgar caución de que se presentaría ante el *iudex*, caso contrario el juicio continua en contumacia de éste. Cabe aclarar que en tiempos del bajo imperio la rebeldía no coloca al demandado en desventaja dado que no se le niega el derecho de defensa ni la posibilidad de producir prueba a través de su representante, si pierde el juicio será por otros motivos no por estar ausente físicamente mientras se sustancia el proceso. Sí va a resultar perjudicado cuando quiera apelar en caso de obtener una sentencia desfavorable, derecho que pierde por su condición de rebelde, con excepción del recurso de reposición. Sin embargo para que se declare la rebeldía deberá ser citado varias veces para que comparezca.

- c) La contumacia puede ser tanto del actor como del demandado.
- d) Si es el actor el que no se presenta el día de la citación, por el distipendio que causó sobre todo para el demandado deberá pagarle una indemnización por daños y perjuicios.

- 2. Procedimiento por Rescripto: Permite que el actor recurra directamente al Emperador para que le designe un juez, tratándose por lo tanto una excepción a las reglas de competencia, éste lo hará por medio de un rescripto que debe ser notificado al demandado –*editiorescripti*– (Novela, 131, 1).

B. La *Litis contestatio*: Es menester que según el paso del tiempo ha tenido diversos significados:

- 1) En tiempos del procedimiento formulario: Era cuando el “actor” le proponía al demandado la fórmula que aprobaba

el pretor y el *reus*-demandado- la aceptaba, comprometiéndose ambos litigantes a acatar la sentencia pronunciada por el *iudex* que debía fallar de acuerdo a los términos de la demanda.

2) En tiempos del proceso extraordinario la *litiscontestatio* o constitución del proceso se da cuando están presentes las partes o ante el juez, el litigio queda contradictoriamente trabado desde el punto de vista jurídico a través de dos exposiciones: la del actor o *narratio* y la del demandado o *contradictio* (Cod. III, 9, 1 y III, 1, 14, 4).

La *litis contestatio* sirve para que el juez determine los elementos con los que cuenta el proceso aunque según reza una Const. De Servero y Antonio del año 202 (Cód. II, 1, 3), sea lícito “enmendar o cambiar” si hubo error;

A partir de la *litis contestatio* empieza a correr un plazo de tres años para la perención de la instancia (Cód. III, XIII, 1).

Luego de la *conventio* y la *contradictio*, tanto las partes como los abogados que las asisten deben prestar ante los Santos Evangelios, según una Constitución de Justiniano recogida en el Código (II, LIX, 2 pr.) el *iusiurandum calumniae*, es decir el juramento de que no litigan maliciosamente.

Además, después de la *litis contestatio* –*narratio* y *contradictio*– comienzan a actuar dichos abogados, desarrollando los argumentos de la demanda y la contestación, mediante la *postulatio* y la *contradictio*, con las cuales concluyen los debates iniciándose la producción de las pruebas, las que deben versar, por parte del actor sobre los hechos invocados en la demanda y del demandado sobre los que sirven de fundamento de sus defensas o excepciones.

La *exceptio*, a diferencia de cómo se daba en el procedimiento formulario en esta nueva etapa subsiste en su aspecto material o de fondo, o sea, como defensa indirecta que puede hacerse valer ante el funcionario-juez conjuntamente con la defensa directa, que consiste en negar en forma acabada las afirmaciones del actor. También se

admitían las llamadas *exceptiones minutoriae*, con el fin de frenar las pretensiones del actor, o dicho de otra manera ponerles límites.

Carga de la prueba

Le Incumbe probar al que alega o afirma - *incumbit probatioei qui dicir, non qui negat*”-, se pierde la libertad de valorar la prueba que tenía el *iudex* durante el procedimiento formulario, en éste período que se está estudiando se le va a dar más valor a unos medios de prueba más que a otros. Tienen primacía aquellos que demuestran los hechos independientemente de la convicción del juez basado en pruebas de menor valor. De éste modo adquieren mayor importancia determinados medios de prueba en desmedro de otros, por ejemplo: la confesión, el juramento, la prueba escrita en general cualquiera que fuese ella y por último los testigos.

Medios de Pruebas

a) Los Testigos

Existieron varias reglas en lo que respecta los testigos, entre ellas: 1) la regla *testis unus testis nullus*.

- Se declara la ineficacia del testimonio de judíos y herejes contra litigantes cristianos u ortodoxos (Const. De Justiniano, en Cód. I, V, 21 pr.),

- Se tiene en cuenta la condición social de los testigos, para valorar sus declaraciones (Cód. IV, XX, 9; Novelas, 90, 1)

b) Los documentos

Entre ellos había distintas clases:

- 1) Los documentos extendidos por oficiales públicos que gozaban provistos del *ius actorum conficiendorum* (derecho de levantar actas), no se discutía en absoluto su valor jurídico probatorio, sin embargo podían ser impugnadas de falsedad.
- 2) Los *instrumenta publice confecta* o documentos públicos